

1500249-46.2021.8.26.0613  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES  
Comarca: São José do Rio Pardo  
Foro: Foro de São José do Rio Pardo  
Vara: 1ª Vara  
Data de Disponibilização: 02/02/2022  
... contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de São José do Rio Pardo  
Foro de São José do Rio Pardo  
1ª Vara  
Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500249-46.2021.8.26.0613 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500249-46.2021.8.26.0613  
Classe - Assunto:  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199526/2021 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 19212190 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 1048/21/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2199526 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ALLAN MARCOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra Allan Marcos da Silva eis que, no dia 23 de julho de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Benedito Maia, altura do nº 17, Conjunto Habitacional Buenos Aires, nesta cidade e comarca, ALLAN MARCOS DA SILVA, com

unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente João Vítor Correia Alexandre, vendia e guardava 08 (oito) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 12,10 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e auto de constatação preliminar de fls. 16/17), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado e o adolescente João Vítor vendiam e guardavam as porções de cocaína acima mencionadas, incorrendo nas iras do art. 33, caput, c.c inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/2006.

A denúncia de págs. 98/100, veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/29.

Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme decisão de págs. 48/54 da lavra do MM. Juiz Plantonista Sansão Ferreira Barreto.

Liminar deferida em Habeas Corpus impetrado perante a 14ª Câmara Criminal do E. TJSP - pg. 73/85.

O réu apresentou defesa preliminar (págs. 143/147), requerendo o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, pois mera aproximação ou permanência no mesmo local não configura que o réu estivesse junto com o adolescente para fins de traficância. Requer a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas..

A denúncia foi recebida aos 13 de dezembro de 2021 oportunidade em que fora designada audiência de instrução - págs. 155/157.

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo e mídia anexada ao SAJ - pgs. 202/204.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Materialidade no laudo de pgs. 121/123. O réu confessa, de modo que a autoria é clara. O policial também flagrou o réu praticando tráfico de drogas na companhia do adolescente citado na denúncia. A droga foi encontrada justamente no local em que os policiais viam a dupla pegando a droga. O réu possui antecedentes infracionais. Na maioridade não ostenta antecedentes. A pena deve ser exasperada diante da participação do menor, não sendo possível que o réu não tivesse desconfiado que o outro rapaz não fosse menor. Ademais os policiais viram o adolescente e o acusado pegando a droga no mesmo local. O delito é de extrema gravidade, requerendo a fixação do regime fechado.

A defesa, por sua vez, manifestou-se que diante da confissão do réu não há falar-se em falta de justa causa ou insuficiência de provas. No entanto, há falta de justa causa para a punição, pois o réu não ostenta maus antecedentes. Sua personalidade não é voltada para o crime. Possui emprego fixo e a quantidade de droga era pequena. Requer o reconhecimento da "atenuante" na terceira fase ou causa especial de diminuição de pena na terceira etapa. Alega a impossibilidade de utilização dos atos infracionais como óbice à minorante. Requer a fixação do regime aberto, afastada a hediondez do crime. Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva.

\*\*\*\*\*

DECIDO.

## 1 - ) SÍNTESE PROBATÓRIA

### 1.1 - ) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 14/15), pelo auto de constatação preliminar de págs. 16/17 e pelo laudo pericial (págs. 121/123).

A massa líquida é de 3,45 gramas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

\*\*\*\*\*

### 1.2 - ) Das provas da autoria.

Tiago Policci informou que a polícia tem conhecimento de que aquele local ocorre tráfico de drogas. Perceberam o revezamento do Allan e outro menor fazendo busca e entrega de drogas para outro veículo. Viram eles entregando algo ao veículo e foram ao local e realizaram a abordagem. Com o réu havia dinheiro e celular e com o menor dinheiro. Numa saída de chuva da calçada estavam as porções de cocaína. Sobre a droga ambos recusaram que estavam traficando. Eles não quiseram falar mais nada. O réu estava com camiseta azul, na filmagem. Ele falou que estava trabalhando, mas as imagens são claras no sentido da traficância. Depois dos fatos o réu ficou preso e não sabia que ele estava em liberdade, mas não o avistou mais.

O réu Allan disse que tem 25 anos. Nunca foi preso, nem processado. É açougueiro e está registrado no empório da Carne. Estudou até o primeiro colegial. Começou a trabalhar na roça e depois entrou no mercado porque sua mãe e irmã não arrumavam serviço. Ouviu o que policial disse. Está correto o que o policial falou. Estava desesperado, cheio de contas, teve que operar o braço. Tinha contas de água e luz para pagar, estavam desesperados. Pediu para eles para que deixassem vender um pouco para pagar suas contas e foi preso junto com o menor. Não conhecia o adolescente. Sabia que era um ponto ali e pediu para ele deixar o réu vender também. João Vítor não é seu parceiro. Ele estava ali e apenas conversou com ele. Apenas foi traficar por causa de desespero.

\*\*\*\*\*

## 2 - ) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros

indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos.

Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que contemplar violação ao princípio da igualdade tratando diversamente o valor de uma testemunha por sua profissão, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a “lei do silêncio”, extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

No presente caso, a versão dos policiais em sede inquisitiva e a versão do policial

Tiago ratificada em juízo permanece hígida, pois o réu confessou os fatos, ratificando as circunstâncias da prisão e cancelando a lisura do procedimento dos policiais.

Não há falar-se em estado de necessidade, pois a justificativa do artigo 24 do Código Penal não se compagina com dificuldades financeiras. O requisito "perigo atual" refere-se a uma situação concreta, imediata, não configurando a excludente um perigo remoto, incerto ou passado como é o caso de falta momentânea de recursos financeiros, pois a ausência de pagamentos gera apenas consequências civis e eventualmente corte de fornecimento de serviços, o que não pode ser considerado algo "perigoso", embora indesejável e capaz de gerar transtornos.

Diante de tal panorama, não se ressente este Juízo de qualquer dúvida a respeito da procedência da ação penal.

À guisa de conclusão, presente a tipicidade delitiva na forma capitulada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

\*\*\*\*\*

### 3 - ) DO VEREDITO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 98/100 para CONDENAR ALLAN MARCOS DA SILVA, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário - súmula 444 do E. STJ.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

No caso concreto, nem mesmo o passado infracional do réu recomenda avaliação desfavorável de sua personalidade, pois os registros de pgs. 116 referem-se a três processos, todos muito antigos. O mais recente deles com data de 14.03.2013 de modo que não se afigura razoável que sejam aquelas anotações consideradas em desfavor do réu.

Na análise determinada pelo art. 42 da Lei de Drogas tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 3,45 gramas, conforme laudo pericial de pgs. 121/123.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

A quantidade-massa é insuficiente para justificar qualquer acréscimo. Todavia, pela quantidade-diversidade não se justifica acréscimo, visto que ele portava consigo

apenas um tipo de droga, não podendo assim, atingir maior clientela.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, no mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes. Em que pese a confissão, tem-se que a pena base encontra-se no mínimo legal o que impede qualquer decréscimo à luz da súmula 231 do E. STJ.

Na terceira fase o réu beneficia-se do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser mitigada em 2/3, resultando 1(um) ano e 8(oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa, considerando a pobreza do réu que está patrocinado por advogada dativa.

Incide, por outro lado, a majorante do inciso VI do art. 40 da mesma lei, pois o réu praticava a traficância em companhia de adolescente. Exaspero a pena em 1/6, quindado-a ao patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

A lei não exige a identidade de desígnios nos moldes da coautoria para a incidência da causa de aumento de pena em questão. Ao mencionar "sua prática envolver", almeja o legislador conferir proteção integral ao adolescente, bastando que de algum modo o menor tenha contato com a conduta delituosa.

Segundo o relato dos policiais, o réu e o adolescente conviviam no mesmo ponto de tráfico e escondiam a droga no mesmo local. Assim, está claro que a conduta do réu estimulou o adolescente a prosseguir no conflito com a Lei, ofertando exemplo negativo para formação do menor.

Ausentes outros fatores alteradores da reprimenda, torna-a DEFINITIVA.

Quanto regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Donde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal

e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 509.578/SP (2019/0133777-0), STJ, Rel. Antônio Saldanha Palheiro DJe 16.05.2019. Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

Em caso análogo, ao apreciar a apelação nº. 0000032-53.2016.8.26.0613, a Colenda 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória proferida por este Juízo, mantendo igualmente a determinação de que o réu inicie o cumprimento da pena sob o regime aberto.

Também a 12ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação nº 0000322-85.2016.8.26.0575 desta comarca manteve o regime inicial aberto com expressa alusão às Súmulas 718 do STF e Súmula 440 do STJ, bem como ao HC STF nº 118.533.

A 16ª Câmara Criminal seguiu o mesmo norte na Apelação nº 0001003-55.2016.8.26.0575 desta Comarca, em acórdão da Relatoria do Eminentíssimo Desembargador Guilherme de Souza Nucci.

Para melhor ilustrar:

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM 1º GRAU. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM DESFAVOR DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PACIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DA TESE NO SENTIDO DA NÃO HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS, SE PRIVILEGIADO NOS MOLDES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. REGIME ABERTO ESCOLHIDO PELO JUÍZO EM COERÊNCIA À QUANTIDADE DE PENA (01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO), PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO AGENTE E DEMAIS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO. (Apelação nº 0002209-93.2017.8.26.0438, 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Diniz Fernando. j. 12.11.2018, Publ. 22.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM COMPROVAM A DESTINAÇÃO DO TÓXICO À MERCANCIA E NÃO AO CONSUMO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO ACERTADA. QUANTIDADE DAS DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DO RÉU QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E HEDIONDEZ DO CHAMADO TRÁFICO PRIVILEGIADO QUE FOI AFASTADA PELO PLENO DO E. STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E OUTRA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação nº 0000109-82.2018.8.26.0616, 10ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Francisco Bruno. j. 08.11.2018, Publ. 12.11.2018).

TJSP-) TRÁFICO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS - CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - CONFIGURAÇÃO - DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO. PRIVILÉGIO - SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - MERA ILAÇÃO - QUANTIDADE POUCA EXPRESSIVA DE MACONHA - NEGATIVA INFUNDADA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS - CRITÉRIO - ART. 42 DO MESMO DIPLOMA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO - HEDIONDEZ

AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HABEAS CORPUS Nº 118.533. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. (Apelação nº 0003964-83.2015.8.26.0322, 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Vico Mañas. j. 05.12.2018, Publ. 07.12.2018).

TJSP-) HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA CONTRA O REGIME PRISIONAL FECHADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ADMISSIBILIDADE - SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA A MOTIVAÇÃO DA R. SENTENÇA, PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NÃO SÓ PORQUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECLAROU A - INCONSTITUCIONALIDADE DE TAL DISPOSITIVO, MAS TAMBÉM PORQUE O PRETÓRIO EXCELSO, NO HABEAS CORPUS Nº 118533/MS, AFASTOU A NATUREZA HEDIONDA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO". ALIÁS, HÁ ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO, ACERCA DA NÃO HEDIONDEZ DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO", SEGUIDA POR ESTA COLENDIA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES OU VINCULANTE DO R. DECISUM DAQUELA CORTE CONSTITUCIONAL, É DE BOM ALVITRE QUE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IGUALDADE, O ENTENDIMENTO EXTERNADO NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS Nº 118.533 SEJA ADOPTADO POR TODOS OS JUÍZES E TRIBUNAIS BRASILEIROS, EVITANDO-SE, COM ISSO, DECISÕES EM SENTIDOS OPOSTOS ACERCA DA MESMA MATÉRIA E QUE SOMENTE AQUELES ACUSADOS QUE POSSUAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA GALGAR TODAS AS INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM BENEFICIADOS PELOS EFEITOS DECORRENTES DA NOVA ORIENTAÇÃO DE QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO POSSUI CARÁTER HEDIONDO. DE RESTO, CABÍVEL, EXCEPCIONALMENTE, O REGIME ABERTO EM FACE DO QUANTUM DA PENA E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 2215577-73.2018.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Moreira da Silva. j. 25.10.2018, Publ. 30.10.2018).

TJSP-) PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO - INDEFERIMENTO - CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - CÁLCULO QUE CONSIDEROU A HEDIONDEZ DO CRIME - INADMISSIBILIDADE - RECENTE JULGAMENTO DO STF QUE ENTENDEU NÃO SER HEDIONDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - HC 118533 - ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DO STF - SÚMULA 512 DO STJ CANCELADA - NATUREZA HEDIONDA AFASTADA - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - DETENTO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - AGRAVO PROVIDO. (Agravado de Execução Penal nº 0013382-10.2018.8.26.0041, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Newton Neves. j. 09.11.2018, Publ. 09.11.2018).

Diante o exposto, incidindo a causa especial de diminuição da pena no presente caso, fica afastado o caráter hediondo da conduta, a despeito do entendimento pessoal deste magistrado.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada, bem como primariedade do réu.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, diante da pobreza do réu, patrocinado por advogada do convênio OAB-DPE.

Não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a substituição não é socialmente recomendável, tampouco suficiente para repressão da grave conduta de tráfico de drogas em companhia de adolescente.

Com espeque nos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's, ficando a cobrança suspensa na forma do § 3º do art. 98 do NCPD cc art. 3º do CPP.



O réu poderá apelar em liberdade, conforme v. Acórdão de pgs. 128/132.

Patrocinado por advogada dativa arbitro os honorários, conforme regras do convênio. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 - ) Expeça-se mandado de prisão no regime aberto e guia de execução definitiva. Faculta-se ao réu apresentar-se espontaneamente em Juízo, evitando a intervenção policial para cumprimento do mandado de prisão. Caso compareça ao fórum, o que deverá fazer nos dias úteis entre as 13:00 e 19:00 horas, sua audiência admonitória será devidamente "encaixada" na pauta regular.
- 2 - ) Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;
- 3 - ) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
- 4 - ) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA